

1520967-55.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas.

Segundo apurado, os réus teriam se associado, de forma relativamente organizada, com o fim de praticarem o tráfico de drogas no local dos fatos. E, conforme o planejado, assim agiram por determinado e considerável tempo.

Ocorre que, em 30 de agosto de 2021, policiais militares em patrulhamento pelo local, já ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1520967-55.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520967-55.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA e GILVANEIDE MELO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Segundo a acusação, no dia 30 de agosto de 2021, por volta das 10h00, na Rua Herbert Arruda Pereira, nº. 10, bairro Pirituba, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, GILVANEIDE MELO DA SILVA e FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA, em unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de entrega por qualquer forma a consumo de terceiros, 59 (cinquenta e nove) porções de "maconha" (THC), com massa líquida de 304,2 (trezentos e quatro gramas e dois decigramas), 235 (duzentas e trinta e cinco) porções de "cocaína", com massa líquida de 171,7 g (cento e setenta e um gramas e um decigrama), 197 (trinta e nove) pedras de "crack", com massa líquida de 39 g (trinta e nove gramas) e 7 (sete) porções de haxixe, totalizando 3,1g (três gramas e um decigrama) da substância, substâncias entorpecentes de uso proscrito na forma da Portaria ANVISA 344/98 e atualizações posteriores, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que, que em data indeterminada, porém anterior a 30 de agosto de 2021, nesta cidade e comarca, FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA e GILVANEIDE MELO DA SILVA, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas.

Segundo apurado, os réus teriam se associado, de forma relativamente organizada, com o fim de praticarem o tráfico de drogas no local dos fatos. E, conforme o planejado, assim agiram por determinado e considerável tempo.

Ocorre que, em 30 de agosto de 2021, policiais militares em patrulhamento pelo local, já conhecido ponto de traficância, avistaram os acusados. GILVANEIDE portava consigo uma bolsa de cor preta, e, ao seu lado, estava FERNANDO que tentou evadir-se quando notou a presença dos policiais. Ambos foram detidos e as drogas localizadas no interior da bolsa, assim como 2 rádios transmissores - HT, 2 aparelhos celulares e R\$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). Em revista pessoal, com FERNANDO, foi encontrada ainda a quantia de R\$ 301,00 (trezentos e um reais).

Os acusados foram presos em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva (fls. 70/73).

A denúncia foi recebida no dia 21 de setembro de 2021 (fls. 115/117).

Os réus foram citados (fls. 145 e 147) e apresentaram resposta à acusação (fls. 166).

Não sendo o caso de absolvição sumária (fls. 167), foi designada audiência de instrução. No curso da instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, os réus foram interrogados.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

Por sua vez, a defesa de Gilvaneide requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a manutenção da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, na fração máxima, a fixação de regime inicial mais brando que o fechado para início do cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão do sursis e, por fim, o reconhecimento do direito ao recurso em liberdade.

A defesa de Fernando pleiteou a absolvição por falta de elementos que justifiquem uma condenação. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a manutenção da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, na fração máxima, a fixação de regime inicial mais brando que o fechado para início do cumprimento de pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a concessão do sursis e, por fim, o reconhecimento do direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade apenas do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/27), laudo de constatação a fls. 35/38, laudo de exame químico toxicológico (fls. 161/164),

laudos pericias dos aparelhos de comunicação (fls. 125/131 e 154/160) e pela prova oral produzida nos autos.

Contudo, entendo que a autoria segura foi demonstrada quando ao crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Com efeito, a Policial Militar Juliana Barbara Agostinho de Carvalho relatou que estava em patrulhamento com o seu colega Thiago, pelo local dos fatos que é conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram a acusada GILVANEIDE portando uma bolsa de cor preta em suas mãos ao lado de FERNANDO. Ao se aproximarem, FERNANDO tentou correr, mas ambos foram detidos. Feita a busca, na bolsa foram encontrados 2 rádios transmissores - HT, 2 aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro, além de porções de cocaína, maconha, crack e haxixe. Em revista pessoal, com FERNANDO foi localizado no bolso de sua calça uma quantia em dinheiro. Feita a revista pessoal em GILVANEIDE nada de ilícito foi encontrado. Ao serem questionados, ambos confessaram que vendem drogas constantemente naquele local, esclarecendo que GILVANEIDE estava substituindo FERNANDO, pois este é responsável pelo período noturno e aquela pelo período diurno, tendo acabado de entregar as drogas para serem vendidas. Disse que quando adentraram a rua os réus já estavam juntos, conversando.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Thiago Maciel Tomé. Contou que o local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Disse que ao visualizar a equipe, FERNANDO tentou fugir do local. Ambos foram presos. As drogas estavam em uma bolsa carregada por GILVANEIDE. Eles disseram que FERNANDO estava no turno da noite e iriam trocar. Tinha cocaína, maconha, crack e haxixe. Foi encontrado em torno de R\$1.600,00, além de rádio comunicador e celular. Já conhecia FERNANDO, porque já o conduziu uma outra vez, mas em outro local distante dali. Quando adentraram à rua os réus estavam um ao lado do outro. Havia dinheiro no bolso de Fernando.

O réu FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA negou os fatos. Disse que estava passando pelo local e conhecia a GILVANEIDE. Como devia um dinheiro a ela foi até lá para fazer o acerto. Contou que neste momento os policiais apareceram. Disse que o policial ouvido relatou que colocaria ele novamente na prisão. Contou que fez um dívida de roupa com a ré foi efetuar o pagamento. A dívida era referente a umas roupas que comprou a sua esposa e estava devendo. Estava com esse dinheiro no bolso, a dívida era em torno de R\$250,00. Trabalhava com o sogro como ajudante de pedreiro. A dívida existia há 4 ou 5 meses.. Não mora perto daquele local, mas estava trabalhando em uma obra próximo ao local, contudo não se recorda o endereço da obra. Estava indo para a obra às 10h00. Reiterou ainda qu estava com o dinheiro no bolso porque as vezes precisa usar a quantia para almoçar. Estava com R\$300,00. Está com 19 anos. Disse que pegou o dinheiro 2 dias antes.

A ré GILVANEIDE MELO DA SILVA foi interrogada e confessou o tráfico de drogas. Disse que realmente estava com a droga, mas não tinha rádio comunicador. Os celulares eram dela e de sua filha. Disse que ficou com o celular da filha dela. Confessou que estava ali vendendo drogas. Contou ser usuária de cocaína e por isso aceitou ali trabalhar. Estava desempregada. Mora com a mãe e dois filhos 09 anos e de 14 anos. Tem quatros filhos. Uma é casada e outro mora com a tia. Já conhecia o Fernando. Como ele estava passando ali, ele parou para conversar. Ele não deu dinheiro a ela. Trabalhava de diarista e não vendia roupas. Usa cocaína desde os 15 anos. Já parou durante a gravidez. Nunca existiu dívida entre ela e o Fernando. Estavam conversando há alguns minutos. Não viu ele sair correndo.

Essa, em síntese, a prova oral colhida.

O conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação dos réus.

Como se verifica, a prática da traficância ficou comprovada pelos elementos de prova produzidos, em especial o relato dos policiais militares ouvidos em Juízo que se mostram coerentes e harmônicos, não deixando dúvidas a respeito da autoria e da dinâmica dos fatos.

Por certo, após presenciarem ambos os réus em atitude suspeita, os agentes policiais optaram por abordá-los, momento em que o réu FERNANDO, após avistar à aproximação da viatura policial, tentou se evadir. Ambos foram detidos, sendo comeles encontradas as porções de drogas que estavam em uma bolsa preta carregada por GILVANEIDE, bem como a quantia em dinheiro, rádios de comunicação e telefones celulares.

Além disso, GILVANEIDE confessou e a versão apresentava por FERNANDO não foi confirmada pela corré que disse jamais ter vendido roupas a ele, não havendo dívidas entre eles.

Assim, claro ficou que os policiais, após realizarem a abordagem, apreenderam, no interior da bolsa preta, 59 (cinquenta e nove) porções de "maconha" (THC), com massa líquida de 304,2 (trezentos e quatro gramas e dois decigramas), 235 (duzentas e trinta e cinco) porções de "cocaína", com massa líquida de 171,7 g (cento e setenta e um gramas e um decigrama), 197 (trinta e nove) pedras de "crack", com massa líquida de 39 g (trinta e nove gramas) e 7 (sete) porções de haxixe, totalizando 3,1g (três gramas e um decigrama) da substância.

O laudo de constatação (fls. 35/38), assim como o laudo químico-toxicológico (fls. 161/164) confirmaram que as substâncias encontradas e apreendidas com o réu eram "maconha", "cocaína" e "crack", substância esta similar à cocaína.

O local, conhecido ponto de venda de drogas, conforme exposto pelos policiais militares, assim como a quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, não deixam dúvidas de que as drogas eram destinadas à traficância.

Ressalta-se não haver nos autos qualquer razão para que os policiais militares incriminassem injustamente o réu. Por certo, estes, assim como os demais agentes da lei, não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria, e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras, tendo elas o mesmo crédito que qualquer testemunha, até que prova em contrário exclua a presunção.

Neste sentido:

"É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações". (STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006).

"Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (STJ - HC n.º 404.514-PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 06/03/2018).

Assim, restou demonstrado que os réus efetivamente traziam consigo, para fins de tráfico, diversos entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por todo o exposto, de rigor a condenação dos réus pela prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Contudo, como bem observado pelo Ministério Público e defesas, não há elementos para comprovar o crime de associação ao tráfico de drogas, pois o mero revezamento de ambos no ponto de venda de drogas não é suficiente para comprovar a organização e divisão de tarefas necessárias a caracterizar o crime do artigo 35 da Lei 11.343/06. Deste modo, é caso de absolvição de ambos os réus.

Assim, apurada a responsabilidade penal, passo à dosimetria da pena, segundo o critério previsto no art. 42 da Lei de Drogas e nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Réu FERNANDO:

Na primeira fase, não há nos autos elementos que permitam desvalorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observando que a quantidade de drogas será utilizada como base na terceira fase de fixação da pena, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, ainda que presente a menoridade relativa, impossível a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não há agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, a despeito da primariedade, observo que o réu havia sido preso em flagrante, também acusado de estar praticando o tráfico de drogas 02 meses antes da data do fato apurado nestes autos (fls. 54). Além disso, ele possui uma passagem na Vara da Infância e Adolescência (fls. 56). Soma-se a isso a grande quantidade de drogas e dinheiro apreendido. Assim, é indevida a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Atento a esses critérios, fica a pena definitiva do acusado estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A quantidade de pena inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do "sursis".

Pela quantidade de pena aplicada, não havendo condenação anterior, o réu iniciará o cumprimento da pena em regime semiaberto.

A ausência de informações a respeito da situação econômica do acusado, que estão sendo defendidos pela Defensoria Pública, determina o arbitramento dos dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 do salário mínimo mensal vigente no país ao tempo do fato.

Ré GILVANEIDE:

Na primeira fase, não há razão para a fixação acima do mínimo legal, deverá esta iniciar em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a atenuante relativa à confissão, contudo, impossível reduzir a pena para patamar abaixo do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosagem da pena, verifico que a ré está com 34 anos e é primária. De outro lado, houve grande quantidade de drogas apreendidas. Assim, entendo que é possível a aplicação da causa de diminuição a que se refere o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, contudo no patamar de 1/3 (um terço). Atenta a esses critérios, fica a pena do acusado estabelecida em 03 (três) anos, 04 (quatro) de reclusão, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Levando em consideração a pena aplicada, o fato de que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado e os motivos indicam que substituição é suficiente para a repressão e prevenção do crime e, ainda, que se trata de medida socialmente recomendável, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena por duas penas restritivas de direitos, consistente em Prestação de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada, sendo àquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo a ser estipulado em audiência, junto a uma das entidades enumeradas no parágrafo 2º, do citado artigo, em local a ser designado pelo Juízo da Execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado e, esta, no pagamento do valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato delituoso, para ser convertido na aquisição de cestas básicas a serem entregues a entidades públicas ou privadas em funcionamento neste Município que possuam destinação social e atuem em prol da comunidade.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, em audiência admonitória a ser designada, caberá indicar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar do condenado, consoante disposto pelo artigo 150, da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que o condenado é facultado cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante. Da mesma forma, caberá ao Juízo da Execução, indicar a entidade beneficiada com a prestação pecuniária (cestas básicas).

Em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta, fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Fixo o valor unitário dos dias-multa no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

Decreto o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, pois resultante do delitiva.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

CONDENAR FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, arbitrados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; ABSOLVER FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA da imputação de infração ao artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

CONDENAR GILVANEIDE MELO DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos, 04 (quatro) de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual substituo por duas penas restritivas de direito nos termos da fundamentação, a serem definidas pelo juízo da execução criminal e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, arbitrados unitariamente em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos; ABSOLVER GILVANEIDE MELO DA SILVA da imputação de infração ao artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Considerando que permaneceram inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva do réu FERNANDO TUMIERO DE OLIVEIRA, reforçadas agora pela condenação, nego a ele o direito de recorrer em liberdade. Oficie-se para transferência do acusado a estabelecimento adequado ao cumprimento da pena, observado o regime semiaberto estabelecido nesta sentença, ressalvada a necessidade de manutenção no fechado, por outra razão. Recomende-se o acusado na prisão.

Por sua vez, sendo a pena corporal da ré GILVANEIDE MELO DA SILVA substituída por restritiva de direitos, poderá ela apelar em liberdade. Expeça-se, com urgência alvará de soltura clausulado.

Evidente que o dinheiro encontrado com os réus era proveniente da venda de drogas. Eles estavam com as drogas e a apreensão ocorreu no mesmo contexto, o que permite concluir que eles estavam traficando quando foram presos. Assim, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal e do artigo 63 e seguintes da Lei 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União.

Transitada em julgado esta sentença:

- a) expeça-se guia de recolhimento definitiva observado o prazo prescricional;
- b) elabore-se cálculo de multa e intimem-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição;
- c) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD);
- d) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF;

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, ficando a exigibilidade suspensa para ambos diante da gratuidade concedida.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA